

2015 年全国硕士研究生招生考试

法律硕士专业基础（非法学）

一、单项选择题：第 1~40 小题，每小题 1 分，共 40 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。

1. 原铁道部部长刘某因受贿罪、滥用职权罪被追究刑事责任，有人认为，在对刘某量刑时“应考虑他对中国高铁建设的贡献”，这种说法违背了我国刑法中的（ ）
A. 罪刑法定原则
B. 刑法适用平等原则
C. 罪责刑相适应原则
D. 主客观相统一原则
2. 下列选项中，属于犯罪对象的是（ ）
A. 赌博的筹码
B. 抢夺的财物
C. 行贿的财物
D. 运输毒品的车辆
3. 甲欲杀死赵某，掐赵某脖子致其休克后，甲以为赵某死亡，将其投入河中，赵某溺水而亡，甲的行为构成（ ）
A. 故意伤害罪（致人死亡）
B. 过失致人死亡罪
C. 故意杀人罪（未遂）
D. 故意杀人罪（既遂）
4. 甲涉嫌犯聚众斗殴罪，在 2010 年 8 月 9 日被抓捕时逃跑，2014 年 6 月 5 日，甲抢夺他人财物，数额特别巨大，下列选项中，正确的是（ ）
A. 甲所犯抢夺罪的追诉期限为 5 年
B. 甲所犯聚众斗殴罪因其逃跑而不受追诉期限的限制
C. 甲所犯聚众斗殴罪的追诉期限从 2010 年 8 月 9 日起计算
D. 甲所犯聚众斗殴罪的追诉期限从 2014 年 6 月 5 日起计算
5. 针对吸毒后在道路上驾驶汽车的现象，有人认为，虽然刑法未规定吸毒驾驶构成犯罪，但是吸毒驾驶和醉酒驾驶具有相同的社会危害性，故而应以危险驾驶罪论处，这种观点属于（ ）
A. 扩大解释
B. 文理解释
C. 类推解释
D. 当然解释
6. 关于故意的认识内容，下列选项中正确的是（ ）
A. 成立受贿罪，要求行为人认识到自己是国家工作人员
B. 成立聚众淫乱罪，要求行为人认识到自己行为的违法性
C. 成立故意毁坏财物罪，要求行为人认识到毁坏财物的数额较大
D. 成立传播淫秽物品罪，要求行为人认识到传播的是淫秽物品
7. 甲 17 周岁时因运输毒品被判处 3 年有期徒刑，刑满释放后不久，又因参加黑社会性质组织贩卖毒品被逮捕，甲属于（ ）
A. 再犯
B. 初犯
C. 一般累犯
D. 特别累犯
8. 甲在某机场到达大厅出口外引爆自制爆炸。置，造成一人轻伤，甲的行为应认定为（ ）
A. 爆炸罪
B. 寻衅滋事罪
C. 故意伤害罪
D. 以危险方法危害公共安全罪
9. 某私营健身机构经理安排会计甲将收取的 50 万元会员费存入甲的存折，供单位日常开支，3 个月后，甲取走存折中全部资金潜逃，甲的行为构成（ ）

- A. 盗窃罪
- B. 职务侵占罪
- C. 侵占罪
- D. 挪用资金罪

10. 甲公司将 3000 公斤生产废料直接倒入河中，该废料遇水反应生成毒气，毒气随风飘至附近数个村庄，致上百村民呼吸系统受损，并造成直接经济损失 100 多万元，甲公司的行为构成（ ）

- A. 污染环境罪
- B. 重大责任事故罪
- C. 投放危险物质罪
- D. 以危险方法危害公共安全罪

11. 空姐甲长期在国外购买化妆品，经无申报通道携带入境，交由其表妹在网店销售，偷逃高额海关关税，获利数额巨大，甲的行为应认定为（ ）

- A. 逃税罪
- B. 走私普通货物、物品罪
- C. 非法经营罪
- D. 为亲友非法牟利罪

12. 甲男将女同事汪某骗至宾馆，要求与之发生性关系，否则在网上散布汪某的不雅照，汪某对甲破口大骂，甲觉得无趣，遂打消奸淫念头离去，甲的行为属于（ ）

- A. 犯罪预备
- B. 犯罪未遂
- C. 犯罪中止
- D. 犯罪既遂

13. 下列情形中，不得适用假释的是（ ）

- A. 因诈骗罪被判处 12 年有期徒刑
- B. 因叛逃罪被判处 15 年有期徒刑
- C. 因放火罪被判处 13 年有期徒刑
- D. 因故意杀人罪被判处 5 年有期徒刑

14. 下列犯罪中，属于结果犯的是（ ）

- A. 放火罪
- B. 故意毁坏财物罪
- C. 私放在押人员罪
- D. 参加黑社会性质组织罪

15. 甲因侵占科研经费被捕，在侦查期间，甲主动供述自己曾和同事一起套取另一科研经费 19 万元用于自己房屋。修，甲供述与他人套取科研经费的行为属于（ ）

- A. 坦白
- B. 立功
- C. 自首
- D. 准自首

16. 甲遇红灯停车时，与路人孙某发生口角，甲下车将孙某打倒在地，驾车离去，孙某坐在马路上，不听他人劝导，拒绝离开，10 分钟后，乙超速驾车经过此处，来不及刹车，将孙某撞死，下列选项中，正确的是（ ）

- A. 甲构成故意伤害罪（致人死亡）
- B. 甲构成寻衅滋事罪
- C. 甲和乙共同构成交通肇事罪
- D. 乙构成交通肇事罪

17. 下列行为中，可以认定为妨害信用卡管理罪的是（ ）

- A. 拾得他人信用卡并使用
- B. 窃得他人信用卡并使用
- C. 使用虚假的居民身份证骗领信用卡
- D. 使用以虚假居民身份证骗领的信用卡

18. 甲冒充公安干警，将正在赌博的张某等四人用手铐铐住，拿走其赌资及随身携带的财物 2 万余元，甲的行为应认定为（ ）

- A. 诈骗罪
- B. 抢劫罪
- C. 招摇撞骗罪
- D. 敲诈勒索罪

19. 甲在医院缴费单上加盖自己私刻的收费章，逃避支付妻子透析治疗费用 17 万余元，甲的行为（ ）

- A. 按诈骗罪定罪处罚
- B. 按伪造事业单位印章罪定罪处罚

C. 按合同诈骗罪定罪处罚

D. 成立紧急避险

20. 甲秘密窃取他人持有的枪支, 该行为同时符合盗窃罪和盗窃枪支罪的犯罪构成, 按照我国刑法理论, 这种情形属于 ()

A. 牵连犯

B. 法条竞合

C. 想象竞合犯

D. 结果加重犯

21. 下列民事权利中, 属于支配权的是 ()

A. 甲对无权代理的追认权

B. 乙对自身肖像的使用权

C. 丙因受欺诈享有的撤销合同的权利

D. 丁被他人打伤享有的请求赔偿的权利

22. 下列选项中, 具备法人资格的是 ()

A. 合伙企业

B. 个体工商户

C. 个人独资企业

D. 一人有限责任公司

23. 下列行为中, 属于从法律行为的是 ()

A. 行纪合同

B. 协议离婚

C. 履行行为

D. 抵押合同

24. 甲系精神病人, 有亲属如下: 母亲, 75 周岁, 瘫痪在床。弟弟, 48 周岁, 工人。儿子, 20 周岁, 在校大学生。女儿, 17 周岁, 无业, 甲的监护人应为 ()

A. 甲母

B. 甲弟

C. 甲子

D. 甲女

25. 甲出差, 委托同事乙照看其 9 周岁儿子丙, 某日, 乙将丙单独留在家中, 自己出去打麻将, 丙在玩耍时将邻居小孩丁打伤, 丁的损害应由 ()

A. 甲单独承担责任

B. 乙单独承担责任

C. 甲、乙承担连带责任

D. 甲承担责任, 乙承担相应的补充责任

26. 甲将一批货物存放于乙的仓库, 提货时发现部分货物丢失, 甲要求乙赔偿损失的诉讼时效期间是 ()

A. 6 个月

B. 1 年

C. 2 年

D. 4 年

27. 甲欠乙 10 万元, 时效期间届满未还, 乙索要时, 甲承诺 2 个月内偿还, 但事后只给付了 2 万元, 乙索要余款时, 甲以 10 万元欠款已超过诉讼时效期间为由拒绝, 并要求乙返还之前给付的 2 万元, 下列选项中, 正确的是 ()

A. 甲应偿还剩余的 8 万元

B. 甲承诺偿还引起诉讼时效中断

C. 甲给付的 2 万元属于不当得利, 乙应返还

D. 甲无权要求乙返还 2 万元, 但剩余的 8 万元可以不偿还

28. 甲 16 周岁, 无业, 依靠父母生活, 某日, 甲向朋友乙借款 2 万元, 用其中的 1 万元买了名牌包送给男友丙, 用 200 元为自己的手机充值, 用余款购买了一张美发店的消费卡, 下列选项中, 正确的是 ()

A. 甲与乙之间的借款合同有效

B. 甲与丙之间的赠与合同无效

C. 甲为手机充值的行为可撤销

D. 甲购买消费卡的行为效力未定

29. 下列选项中, 属于所有权继受取得方式的是 ()

A. 添附

B. 先占

C. 生产

D. 遗赠

30. 甲下班时误将同事的同款电脑当成自己的电脑带回家, 甲对该电脑的占有属于 ()

A. 有权占有

B. 间接占有

C. 善意占有

D. 他主占有

31. 甲上晚自习时拾得一个单反相机，后相机被乙借走，乙看到悬赏 200 元的寻物启事，未经甲同意将相机还给了失主，下列选项中，正确的是（ ）

- A. 甲、乙均有权要求失主支付报酬
- B. 仅甲有权要求失主支付报酬
- C. 仅乙有权要求失主支付报酬
- D. 甲、乙均无权要求失主支付报酬

32. 甲向某电脑公司购买一批电脑送给母校，甲指示电脑公司将电脑交给学校，并将订货情况通知了学校，后电脑公司委托某快递公司将电脑运至学校，运输过程中两台电脑毁坏，下列选项中，正确的是（ ）

- A. 甲有权要求电脑公司承担违约责任
- B. 甲有权要求快递公司承担违约责任
- C. 学校有权要求电脑公司承担侵权责任
- D. 学校有权要求快递公司承担侵权责任

33. 甲将住房出租给乙，签订合同前乙来看房，发现室内有很浓的修气味，甲告诉乙，开开窗，过几天味道就没了，乙住了 2 个月后，气味依然很浓，经检测，该房屋有害气体严重超标，对此，乙（ ）

- A. 无权主张任何权利
- B. 有权解除合同
- C. 有权请求确认合同无效
- D. 有权要求甲承担侵权责任

34. 甲在《雾都》杂志发表了一部小说，未作版权声明，某读者阅读后十分喜欢，遂推荐给《传奇文摘》杂志社，《传奇文摘》杂志社若转载该小说，则（ ）

- A. 不必经甲同意，但应向甲支付稿酬
- B. 必须经甲同意，但不必向甲支付稿酬
- C. 不必经《雾都》杂志社同意，但应向其支付稿酬
- D. 必须经《雾都》杂志社同意，但不必向其支付稿酬

35. 甲公司擅自使用电视剧《华妃传》中华妃扮演者的剧照为某化妆品做广告，甲公司的行为侵害了（ ）

- A. 华妃扮演者的肖像权
- B. 华妃扮演者的名誉权
- C. 《华妃传》著作权人的著作权
- D. 《华妃传》著作权人的邻接权

36. 甲在某饭店醉酒闹事，饭店员工和就餐顾客纷纷躲闪，顾客乙躲闪不及被甲打伤，乙的损失应由（ ）

- A. 甲单独承担责任
- B. 甲和饭店承担连带责任
- C. 饭店承担责任，甲承担相应的补充责任
- D. 甲承担责任，饭店承担相应的补充责任

37. 甲超速驾驶汽车，乙逆行骑摩托车，两车相撞，摩托车飞至人行道，将行人丙砸伤，丙的损失应由（ ）

- A. 甲单独承担责任
- B. 乙单独承担责任
- C. 甲、乙承担连带责任
- D. 甲、乙承担按份责任

38. 甲承租乙的房屋，某日，甲在阳台上修剪花草，顺手将剪刀放在阳台边上，不料剪刀被大风吹落，扎伤行人丙，丙的损失应由（ ）

- A. 甲单独承担责任
- B. 乙单独承担责任
- C. 丙自行承担
- D. 甲、乙共同承担责任

39. 甲向乙银行贷款，以其别墅设定抵押，之后，甲在别墅院内建造了独立车库，贷款到期，甲无力偿还，乙银行享有优先受偿权的财产（ ）

- A. 仅限于别墅
- B. 包括别墅、车库

- C. 包括别墅、建设用地使用权
- D. 包括别墅、车库及建设用地使用权

40. 某公安局官方微博公布了演员甲因容留他人吸毒被抓的消息，一知名记者在其博客上转载该消息，并上传了甲与艺人乙、丙一起赌博的照片，该记者的行为（ ）

- A. 侵害了甲的隐私权
- B. 侵害了乙、丙的肖像权
- C. 侵害了乙、丙的隐私权
- D. 不构成侵权

二、多项选择题：第 41~50 小题，每小题 2 分，共 20 分，下列每题给出的四个选项中，至少有两个选项是符合题目要求的，多选、少选或错选均不得分。

41. 下列犯罪中，属于我国刑法所规定的告诉才处理的有（ ）

- A. 重婚罪
- B. 侮辱罪
- C. 暴力干涉婚姻自由罪
- D. 遗弃罪

42. 下列选项中，属于法律认识错误的有（ ）

- A. 甲以为在网上窃取“Q 币”不犯罪而为之
- B. 乙以为杀死他人可以驱除恶灵而杀死他人
- C. 丙以为夜间在道路上追逐竞驶不犯罪而为之
- D. 丁把他人灌醉后拿走其随身财物，辩称自己犯的是盗窃罪

43. 下列选项中，依法不得适用死刑的有（ ）

- A. 审判时怀孕的妇女
- B. 审判时已满 75 周岁的人
- C. 犯罪时不满 18 周岁的人
- D. 犯罪时又聋又哑的人

44. 下列行为中，应以非法经营罪（不考虑数额或者情节）定罪处罚的有（ ）

- A. 甲在生产的饲料中添加“瘦肉精”
- B. 乙私设转接设备，擅自经营国际电信业务
- C. 丙组织多人出卖人体器官，并从中获取介绍费
- D. 丁用 POS 机为他人刷信用卡套取现金，赚取手续费

45. 甲在某学校附近利用“地沟油”生产“食用油”，被刘某举报，甲因此被判处有期徒刑 1 年，缓刑 2 年，同时宣告禁止令，关于该禁止令的适用，正确的是（ ）

- A. 禁止甲接触刘某
- B. 禁止甲进入学校
- C. 禁止甲从事食用油生产经营行业
- D. 禁止令的执行期限从缓刑考验期满之日起计算

46. 甲离家出走，下落不明已满 5 年，下列人员中，可向人民法院申请甲为失踪人的有（ ）

- A. 甲的妻子
- B. 甲的姐姐
- C. 甲的债权人
- D. 甲的外祖父

47. 甲、乙系对门邻居，同时。修房屋，某日，在甲家。修的丙公司工人丁误将乙堆放在公共过道上的瓷砖当成甲所有，贴到甲家厨房墙壁，乙可以要求（ ）

- A. 甲返还原物
- B. 甲返还不当得利
- C. 丙公司赔偿损失
- D. 丙公司与丁承担连带责任

48. 甲乙约定，甲租住乙的别墅 15 年，租赁期间，甲将房屋加高，使邻居丙的房屋采光受到严重影响，对此，丙（ ）

- A. 可以侵害相邻权为由要求甲排除妨碍
- B. 可以侵害相邻权为由要求乙排除妨碍
- C. 无权要求乙排除妨碍，因为将房屋加高系甲所为
- D. 可以侵害建筑物区分所有权为由要求乙排除妨碍

49. 甲医院误将患者乙的左肾切除，甲医院有义务赔偿乙的（ ）

- A. 精神损害
- B. 后续治疗费用
- C. 护理费和交通费
- D. 因误工减少的收入

50. 甲与妻子乙协议离婚，约定 8 周岁儿子由乙抚养，甲支付抚养费，后甲与有一女儿的丙再婚，并在婚后继续给付儿子抚养费，10 年后，丙因病去世，丙去世时，其近亲属还有姐姐丁，有权继承丙遗产的人有（ ）

- A. 甲
- B. 甲的儿子
- C. 丙的女儿
- D. 丁

三、简答题：第 51~54 小题，每小题 6 分，共 24 分。

- 51. 简述缓刑的适用条件
- 52. 简述组织、领导、参加恐怖组织罪的构成要件
- 53. 简述职务发明创造的具体类型
- 54. 简述滥用代理权的主要情形及其效力

四、辨析题：第 55、56 小题，每小题 8 分，共 16 分，要求对命题进行判断并着重阐明理由。

- 55. 请对“没有因果关系，就没有刑事责任”这一说法加以辨析
- 56. 请对“不动产物权不经登记不得设立”这一说法加以辨析

五、法条分析题：第 57、58 小题，每小题 10 分，共 20 分，要求符合立法原意和刑法、民法理论。

57. 我国《刑法》第 397 条第 1 款规定：“国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的，处 3 年以下有期徒刑或者拘役。情节特别严重的，处 3 年以上 7 年以下有期徒刑，本法另有规定的，依照规定。”

请分析：

- (1) 本条款中“滥用职权”的含义。
- (2) 本条款中“玩忽职守”的含义。
- (3) 本条款中“本法另有规定的，依照规定”的含义。

58. 我国《民法典》第 1052 条规定：因胁迫结婚的，受胁迫的一方可以向人民法院请求撤销婚姻，请求撤销婚姻的，应当自胁迫行为终止之日起 1 年内提出，被非法限制人身自由的当事人请求撤销婚姻的，应当自恢复人身自由之日起 1 年内提出。

请问：

- (1) 本条所称“胁迫”应如何理解？
- (2) 有权以胁迫为由请求撤销婚姻的主体是谁？
- (3) 本条中的“1 年”是何种性质的期间？

六、案例分析题：第 59、60 小题，每小题 15 分，共 30 分。

59. 2010 年 3 月 1 日，甲（男，1992 年 12 月 10 日出生）和乙（女，1995 年 8 月 1 日出生）为购买高

档手机骗走邻居家 3 岁的小孩，准备将其卖出，两人将孩子关在城郊一处废弃库房后，甲去外地寻找买主，并安排乙看管孩子，孩子哭闹不休，乙难以忍受，离开库房，弃之不顾，甲得知乙不在库房，就要求乙返回，乙不予理会，最终导致孩子饿死。

请根据上述案情，回答下列问题并说明理由：

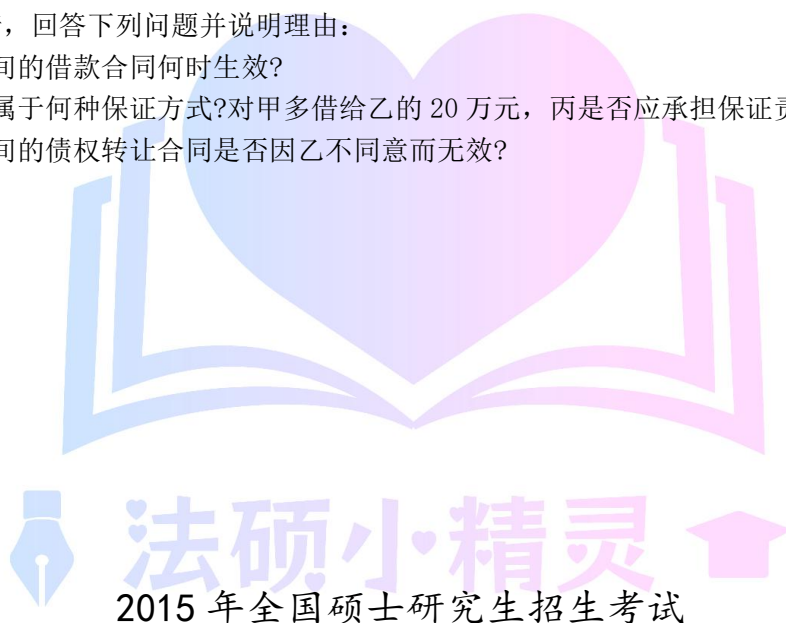
- (1) 甲的行为如何定罪？
- (2) 乙的行为如何定罪？
- (3) 甲和乙是否构成共同犯罪？

60. 2012 年 4 月初，甲与乙、丙签订借款合同，约定：甲借给乙 120 万元，期限 2 年，乙每月偿还 5 万元。丙承担保证责任，如乙到期无力还款，由丙向甲偿还全部借款，合同签订后，乙请求甲再多借给自己 20 万元，甲表示同意，并于 2012 年 4 月 28 日将 140 万元借款交给乙，乙出具借据，载明收到 140 万元，还款期限顺延，丙对此不知情。

2012 年 5 月至 2012 年 12 月底，乙共计还款 40 万元，2013 年 1 月，甲与丁签订债权转让合同，将甲对乙的债权转让给丁，合同签订后，甲向乙、丙发出债权转让通知书，乙收到后明确表示不同意，丙则未置可否。

请根据上述案情，回答下列问题并说明理由：

- (1) 甲与乙之间的借款合同何时生效？
- (2) 丙的担保属于何种保证方式？对甲多借给乙的 20 万元，丙是否应承担保证责任？
- (3) 甲与丁之间的债权转让合同是否因乙不同意而无效？



法律硕士专业基础（非法学）参考答案

一、单项选择题

1. 【答案】C

【解析】罪刑法定原则明显不相关，A 选项可以排除，刑法适用平等原则是不允许任何人有超越法律的特权，应当做到同案同判，本案中，有人主张应考虑刘某对中国高铁建设的贡献，并未将刘某案与其他案件相对比，故并未违反该原则，B 选项不当选，主客观相统一这一说法，虽然我们在刑法中经常提到，但其并非是刑法的基本原则，故 D 选项不当选，罪责刑相适应原则也称罪刑等价主义或者罪刑相均衡原则，《刑法》第 5 条规定：“刑罚的轻重，应当与犯罪分子所犯罪行和承担的刑事责任相适应，”据此，刑法规定的罪责刑相适应原则有两方面内容：①刑罚的轻重与客观的犯罪行为及其危害结果相适应，就是按照犯罪行为对社会造成的实际危害程度决定刑罚轻重，②刑罚的轻重与犯罪人主观恶性的深浅、再次犯罪危险性的大小相适应，在裁量刑罚时，应尽量使刑罚与具体犯罪行为的社会危害性相适应，罚当其罪，原铁道部部长刘某因受贿罪、滥用职权罪被追究刑事责任，有人认为，在对刘某量刑时“应考虑他对中国高铁建设的

贡献”，违背了罪责刑相适应原则，因为决定一个人的刑事责任的大小完全取决于其行为与主观恶性，与其他因素无关，故 C 选项当选。

2. 【答案】B

【解析】犯罪对象与组成犯罪之物不同，用于贿赂、赌博的财物，是组成贿赂罪、赌博罪之物，不是贿赂罪、赌博罪的犯罪对象，故 AC 选项不当选，抢夺的财物属于犯罪对象，B 选项当选。而运输毒品的车辆属于犯罪工具即犯罪所用之物，D 选项不当选。

3. 【答案】D

【解析】甲的行为属于事实认识错误中的因果关系错误，是指行为人对自己的行为和所造成的结果之间因果关系的实际情况发生误认，因果关系的认识错误对罪责的认定均不发生影响，故甲成立故意杀人罪既遂，因此，本题答案为 D。

4. 【答案】B

【解析】关于抢夺罪，《刑法》第 267 条第 1 款规定，抢夺公私财物，数额较大的，或者多次抢夺的，处 3 年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。数额巨大或者有其他严重情节的，处 3 年以上 10 年以下有期徒刑，并处罚金。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处 10 年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产，甲抢夺财物数额特别巨大，最高刑为无期徒刑，法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过 20 年，不再追诉，所以 A 选项错误，在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者在人民法院受理案件以后，逃避侦查或者审判的，不受追诉期限的限制，所以 B 选项正确，《刑法》第 89 条第 1 款规定，追诉期限从犯罪之日起计算。犯罪行为有连续或者继续状态的，从犯罪行为终了之日起计算，这里的“犯罪之日”是指犯罪成立之日，除了继续犯或连续犯以外，其他犯罪的追诉期限应从犯罪成立之日起计算，因此，甲所犯聚众斗殴罪应从聚众斗殴之日起计算，而非公安抓捕之日，即 2010 年 8 月 9 日起算，《刑法》第 89 条第 2 款规定，在追诉期限以内又犯罪的，前罪追诉期限应从犯后罪之日起计算，这是刑法关于追诉期限中断的规定，表面上看，甲所犯聚众斗殴罪的追诉期限应从犯后罪之日起计算，即 2014 年 6 月 5 日即抢夺之日起计算，但是由于甲有逃避侦查或审判的行为，任何时间都可以对其追诉，不再适用追诉期限中断的规定，既符合追诉期限延长，又符合追诉期限中断的，应当优先适用追诉期限延长，CD 选项错误。

5. 【答案】C

【解析】根据解释的方法，刑法解释可分为文理解释和论理解释，文理解释是根据条文的字面含义进行的说明，论理解释是根据立法的精神与目的对条文进行说明，一般认为，论理解释包括目的解释、扩大解释、缩小解释、当然解释、比较解释和历史解释等，具体到本题，由于对于危险驾驶罪，《刑法》第 133 条之一规定，在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：①追逐竞驶，情节恶劣的。②醉酒驾驶机动车的。③从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的。④违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的，机动车所有人、管理人对前款第 3 项、第 4 项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚，有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚，可见，刑法未规定吸毒驾驶构成犯罪，虽然吸毒驾驶和醉酒驾驶具有相同的社会危害性，但是不能以危险驾驶罪论处，因为这本身已经超越了刑法文本可能具有的含义，违背了罪刑法定原则，亦即将吸毒驾驶机动车的行为评价为危险驾驶罪属于类推解释，故 C 选项当选，需要说明的是，扩大解释和类推解释都从字面含义上进行了扩大，但是其区别在于是否超过了国民预测可能性，将吸毒驾驶解释为醉酒驾驶，本质上将吸毒解释为喝酒，明显超过了国民预测可能性，故属于类推。

6. 【答案】D

【解析】故意的认识内容包括：①对行为、结果以及它们之间的因果关系这样的客观事实的明确认识，具体而言是对犯罪构成事实所属情况的认识，例如，走私、运输、贩卖毒品罪的故意，必须对走私、运输贩卖行为和对象是毒品有认识，如果行为人不知道某种物体是毒品而携带、运输、贩卖的，不能成立该种

犯罪的故意，②对行为及其结果具有社会危害性的认识，这是对犯罪故意进行否定评价的根据，故意的显著特征是明知不可为而为之，因此故意的认识内容应包括行为人知道自己的所作所为是损害社会或者他人利益的，是“坏事”，有此认识，意味着行为人知其不可为，如果行为人明知其不可为而为之，是应当受到国家的谴责和惩罚的，行为人对社会危害的认识与对自己行为的违法性认识通常是一致的，基于此，成立受贿罪，不要求行为人认识到（但有认识的可能性）自己是国家工作人员。成立聚众淫乱罪，不要求行为人认识到（但有认识的可能性）自己行为的违法性，只需要认识到特定的构成要件事实即可。成立故意毁坏财物罪，不要求行为人认识到（但有认识的可能性）毁坏财物的数额较大，只要求行为人认识到毁坏的对象是财物即可，故 ABC 选项错误，成立传播淫秽物品罪，要求行为人认识到传播的是淫秽物品，故 D 选项正确。

7. 【答案】A

【解析】一般意义上的再犯，是指再次犯罪的人，即两次或者两次以上实施犯罪的人，对再犯的后犯之罪实施的时间并无限制，既可以是在前罪刑罚执行期间实施的，也可以是在刑满释放之后实施的，累犯与再犯的区别主要体现在：①累犯前后实施的犯罪必须是特定的犯罪，而再犯前后实施的犯罪并无此方面的限制，②累犯一般必须以前后两罪已经被判处或者应判处一定刑罚为构成要件，而构成再犯，并不要求前后两罪必须被判处一定刑罚，③累犯所犯后罪，一般必须是在前罪刑罚执行完毕或者赦免以后的法定期限内实施的。而构成再犯，对前后两罪之间并无时间方面的限制，甲的行为属于再犯，A 选项当选，累犯的成立要求行为主体实施前罪与后罪时，都必须已满 18 周岁，CD 选项不当选。

8. 【答案】A

【解析】以危险方法危害公共安全罪是指故意使用放火、决水、爆炸、投放危险物质以外的危险方法危害公共安全的行为，属于兜底性的罪名，能够认定为具体的罪名的，就认定为具体的罪名，爆炸罪即故意针对不特定的多数人或者重大公私财产实施爆炸行为，危害公共安全的行为，甲的行为危害了公共安全，符合爆炸罪的构成要件，故 A 选项当选，甲的行为不是简单的寻衅滋事，扰乱社会公共秩序，故 B 选项不当选。

9. 【答案】B

【解析】盗窃罪是将他人占有的财物以秘密手段转移为自己占有，由于这 50 万元本身就由甲在占有，甲的行为没有破坏他人对财物的占有关系，故不构成盗窃，A 选项错误，职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占有，数额较大的行为，挪用资金罪是指公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大，超过 3 个月未还的，或者虽然没有超过 3 个月，但是数额较大，进行营利活动，或者进行非法活动的行为，甲利用职务上的便利，将本单位财物非法占有，成立职务侵占罪，因此，本题答案为 B，侵占罪的对象是代为保管的他人财物、遗忘物、埋藏物，虽然可将 50 万元解释为代为保管的他人财物，但是职务侵占罪是特殊法条，应当优先适用，挪用资金罪的行为人主观上对单位资金没有非法占有目的，本案中甲携带 50 万元资金潜逃，表明其主观上有非法占有单位财物的目的，故 D 选项错误。

10. 【答案】A

【解析】污染环境罪是指违反国家规定，排放、倾倒或者处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质或者其他有害物质，严重污染环境的行为，投放危险物质罪是指故意针对不特定的多数人或者重大公私财产投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质，危害公共安全的行为，行为人甲公司投入河流的生产废料本身并非“毒害性、放射性、传染病病原体等物质”，但是该行为严重污染了环境，所以成立污染环境罪，由于以危险方法危害公共安全罪属于兜底罪名，不成立投放危险物质罪，同样不成立以危险方法危害公共安全罪，重大责任事故罪，是指在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为，甲公司并非在生产、作业中违反有关安全管理的规定，而是投入生产废料污染了环境，重大责任事故罪属于过失犯罪，而甲公司故意将生产废料直接倒入河中，造成严重后

果，是故意犯罪，因此甲不成立此罪，投放危险物质罪、以危险方法危害公共安全罪均属于自然人犯罪而非单位犯罪，题目问甲公司成立何罪，只能是污染环境罪，因此，本题答案为 A。

11. 【答案】B

【解析】走私普通货物、物品罪是指违反海关法规，逃避海关监管，非法运输、携带、邮寄国家禁止进出口的武器、弹药、核材料、假币、珍贵动物及其制品、珍稀植物及其制品、淫秽物品以及国家禁止出口的文物、金银和其他贵重金属以外的其他货物、物品进出境，偷逃应缴纳税款数额较大或者 1 年内曾因走私受到 2 次行政处罚后又走私的行为，甲通过走私化妆品在其表妹网店销售，完全符合走私普通货物、物品罪的犯罪构成要件，故 B 选项当选，逃税罪是指纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假的纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额 10% 以上或者扣缴义务人采取欺骗、隐瞒手段，不缴或少缴已扣、已收税款，数额较大的行为，故 A 选项不当选，非法经营罪是指违反国家规定，非法经营，扰乱市场秩序，情节严重的行为，故 C 选项不当选，为亲友非法牟利罪的行为主体是国有公司、企业、事业单位的工作人员，故 D 选项不当选。

12. 【答案】C

【解析】犯罪中止中行为人自动中止犯罪不必一律达到真诚悔悟的程度，犯罪人真诚悔悟是自动性最典型、最理想的情况，但却不是成立中止的要件，犯罪人因为他人规劝或者害怕受到刑罚的惩罚、上天的报应等而放弃犯罪的，即使其内心并未达到真诚悔悟的程度，也不妨碍其成立犯罪中止，犯罪中止的自动性的要点是“自主放弃犯罪”，甲在实施强奸行为的过程中，虽然没有真诚悔悟，只是觉得“无趣”，在能继续实施犯罪的情况下依然放弃犯罪，即“能而不欲”，所以仍成立犯罪中止，C 选项当选，由于甲已经着手，故不成立犯罪预备，同时，普通强奸罪的既遂标准为“插入说”，奸淫幼女型强奸罪的既遂标准为“接触说”，故甲不成立强奸罪既遂。

13. 【答案】C

【解析】对累犯以及因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪被判处 10 年以上有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，不得假释，因此，C 选项当选。

14. 【答案】B

【解析】实害犯即结果犯，是指行为必须已造成法定的实害后果，才是该罪的既遂，危险犯的特征是发生侵害法益的现实危险是既遂的要件，只要行为足以造成某种严重后果发生的危险，就是该罪的既遂，行为犯的特征是犯罪行为实施到一定程度即构成既遂，只要实行了某种犯罪行为，就是该罪的既遂，放火罪属于危险犯。故意毁坏财物罪属于结果犯。私放在押人员罪属于行为犯。参加黑社会性质组织罪属于行为犯，故 B 选项当选。

15. 【答案】A

【解析】（1）一般自首，是指犯罪分子犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的行为，特别自首，亦称准自首，是指被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的行为，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚，其中，犯罪较轻的，可以免除处罚，因为甲是被动归案，所以不成立一般自首。另外，只有甲如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行，才能构成准自首，而甲如实供述的罪行与司法机关已经掌握的是同种罪行，故不成立准自首，甲的行为不属于自首，故 CD 选项不当选。

（2）坦白则是犯罪人被动归案之后，如实交代自己被指控的犯罪事实的行为，犯罪嫌疑人虽不具有自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚。因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚，甲的行为成立坦白，故 A 选项当选。

（3）所谓立功，是指犯罪分子揭发他人犯罪行为，查证属实，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件的行为，对于立功犯应分别依照以下不同情况予以从宽处罚：犯罪分子有一般立功表现的，可以从轻或者减轻处罚。犯罪分子有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚，根据司法解释的规定，共同犯罪案

件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实，应当认定为有立功表现，如果揭发的是同案犯共同犯罪的案件事实，是其如实供述的义务，不能认定为立功，甲主动供述和同事一起套取科研经费 19 万元的事实，属于供述共同的犯罪事实，甲的行为不成立立功，故 B 选项不当选。

16. 【答案】D

【解析】甲的伤害行为实施后，介入因素即车祸的行为过于异常且独立导致结果的发生，中断了甲的行为与孙某死亡结果之间的因果关系，故甲不构成故意伤害罪（致人死亡），A 选项错误，寻衅滋事罪是指行为人为寻求刺激、发泄情绪、逞强耍横等，无事生非，进行扰乱破坏，情节恶劣的行为，寻衅滋事罪保护的客体是社会管理秩序，所以行为人因婚恋、家庭、邻里、债务等纠纷，实施殴打、辱骂、恐吓他人或者损毁、占用他人财物等行为的，如果没有妨害到社会管理秩序，一般不认定为“寻衅滋事”，甲只是偶发性地与路人发生纠纷，不应认定为寻衅滋事罪，故 B 选项错误，交通肇事罪是过失犯罪，原则上不能构成共同犯罪，根据司法解释的规定，交通肇事后，单位主管人员、机动车辆所有人、承包人或者乘车人指使肇事人逃逸，致使被害人得不到救助而死亡的，以交通肇事罪共犯论处，本案中，甲并非肇事人，乙也未指使逃逸，孙某也非得不到及时救助而死亡，故甲乙不成立交通肇事罪的共犯，孙某作为成年人应该知道坐在路中央所面临的风险，仍然拒绝离开，导致同样违反交通运输管理法规的乙撞死孙某，因此，乙成立交通肇事罪，甲无罪，故本题答案为 D。

17. 【答案】C

【解析】妨害信用卡管理罪是指违反信用卡管理法律、法规的规定，妨害信用卡管理的行为，妨害信用卡管理的行为包括：①明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的。②非法持有他人信用卡，数量较大的。③使用虚假的身份证明骗领信用卡的。④出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领信用卡的行为，信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的，使用法定方法进行信用卡诈骗活动，数额较大的行为，这些方法包括：①使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的。②使用作废的信用卡的。③冒用他人信用卡的。④恶意透支的，盗窃信用卡并使用的，依照盗窃罪定罪处罚，AD 选项成立信用卡诈骗罪，B 选项成立盗窃罪，均不当选。C 选项成立妨害信用卡管理罪，当选。

18. 【答案】B

【解析】行为人冒充正在执行公务的人民警察“抓赌”“抓嫖”“没收赌资”“罚款”的行为构成犯罪的，以招摇撞骗罪从重处罚。在实施上述行为中使用暴力或者暴力威胁的，以抢劫罪定罪处罚，行为人冒充治安联防队员“抓赌”“抓嫖”“没收赌资”“罚款”的行为构成犯罪的，以敲诈勒索罪定罪处罚。在实施上述行为中使用暴力或者暴力威胁的，以抢劫罪定罪处罚，甲冒充公安干警，将正在赌博的张某等四人用手铐铐住，压制被害人的反抗，拿走其赌资及随身携带的财物 2 万余元的行为成立抢劫罪，故本题答案为 B。

19. 【答案】A

【解析】伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪是指没有制作权限的人，擅自伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的行为，甲的行为成立伪造事业单位印章罪同时触犯诈骗罪，两者属于牵连犯，应当择一重罪处罚，定诈骗罪即可，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为，甲的行为明显不是发生在签订、履行合同过程中，而且合同诈骗罪是扰乱市场秩序的犯罪，要求合同的双方至少有一方是从事市场经营的主体，我国通说认为，医疗服务具有公益性、福利性，并非为了谋取特定的市场利润，所以不成立合同诈骗罪，故本题答案为 A。

20. 【答案】B

【解析】抛开具体的案件事实，就法条本身来说，盗窃罪与盗窃枪支罪就属于一般法与特别法的关系，因此本题情形属于法条竞合的关系，按照法条竞合的原则处理，故本题答案为 B。

21. 【答案】B

【解析】支配权，亦称“管领权”，是指权利主体所享有的对权利客体直接管领和控制的权力，如物权、人格权、知识产权等，请求权是指权利人得请求他人为一定行为或者不为一定行为的权利，如债权请求权、物权请求权、损害赔偿请求权等，形成权是指当事人一方的意思表示就可使法律关系发生变化的权利，形成权按其作用分为三种：使法律关系发生的形成权，如本人对无权代理行为的追认权。使法律关系发生变更的形成权，如选择之债的选择权。使法律关系终止的形成权，如撤销权、抵销权等，AC 选项属于形成权，D 选项属于请求权，此处部分考生存在判断上的混淆，丁被打伤，属于健康权受到伤害，因为健康权受到侵害而产生了请求损害赔偿的权利，这权利在性质上属于支配权请求权，即因支配权受到侵害后而产生的请求权，本质为请求权。肖像权，是指人对自己的肖像享有使用并排除他人侵害的权利，即以人对自己的肖像上所体现的以人格利益为内容的一种人格权，该人格权属支配权，所以 B 选项当选。

22. 【答案】D

【解析】法人是具有民事权利能力和民事行为能力，并依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人具有以下特征：①法人是一种依法成立的社会组织；②法人有独立的财产或者经费；③法人能够以自己的名义参加民事活动；④法人是能够独立承担民事责任的社会组织。合伙人对合伙企业的债务承担无限清偿责任，自然人对个体工商户、个人独资企业的债务承担无限清偿责任，ABC 选项均不能独立承担民事责任，不具备法人资格。只有 D 选项的一人有限责任公司具备法人的基本特征，具备法人资格。所以本题答案为 D。

23. 【答案】D

【解析】本题考查民事权利的分类之主权利与从权利。主法律行为是指不需要有其他法律行为即可独立成立的法律行为；从法律行为是指从属于其他法律行为而存在的法律行为，从法律行为的成立和效力取决于主法律行为。担保权是典型的从权利，设定担保权的行为即为从法律行为。在担保人为担保债权的实现而设定抵押合同的情形下，借款合同是主民事法律行为，抵押合同为从民事法律行为，故 D 选项当选。AB 选项属于单独的法律行为，不当选。C 选项的行为属于事实行为，而不是法律行为，不当选。

24. 【答案】C

【解析】《民法典》第 28 条规定，无民事行为能力或者限制民事行为能力的成年人，由下列有监护能力的人按顺序担任监护人：①配偶；②父母、子女；③其他近亲属；④其他愿意担任监护人的个人或者组织，但是须经被监护人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意。甲女为未成年人，不在监护人范围内，D 选项不当选。甲母和甲子在监护人范围内，但甲母没有监护能力，A 选项不当选。甲的监护人应为甲子，C 选项当选。甲子作为监护人的顺序在甲弟之前，所以甲弟不选，B 选项不当选。如果题目问的是谁可以成为甲的监护人，则 B 选项可以当选。

25. 【答案】无（原答案为 C）

【解析】《民法典》第 1189 条规定：“无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害，监护人将监护职责委托给他人的，由监护人承担侵权责任；受托人有过错的，承担相应的责任。”本题中监护人应承担赔偿责任，受托人应承担与其过错相应的责任，而不是连带责任。故本题无正确选项。

26. 【答案】无（原答案为 B）

【解析】诉讼时效是指民事权利受到侵害的权利人在法定的时效期间内不行使权利，而于期间届满时，由义务人取得时效抗辩权的法律制度。诉讼时效可分为短期诉讼时效、长期诉讼时效和最长诉讼时效。根据原《民法通则》第 136 条的规定，下列情况下，诉讼时效期间为 1 年：①身体受到伤害要求赔偿的；②出售质量不合格的商品未声明的；③延付或拒付租金的；④寄存财物被丢失或者毁损的。甲存放在乙的仓库的部分货物丢失，则甲要求乙赔偿损失的诉讼时效期间是 1 年，B 选项当选，ACD 选项不当选。但是，考生需要注意的是，《民法典》生效后，取消了短期诉讼时效的规定，并且将普通诉讼时效延长至 3 年，所以本题旧题新做时，则无答案，本题现在的法律依据为《民法典》第 188 条第 1 款：“向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为 3 年，法律另有规定的，依照其规定，”考生只需记住该条即可。

27. 【答案】A

【解析】最高人民法院《关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第19条第1款规定：“诉讼时效期间届满，当事人一方向对方当事人作出同意履行义务的意思表示或者自愿履行义务后，又以诉讼时效期间届满为由进行抗辩的，人民法院不予支持。”债务人作出分期履行、部分履行、提供担保、请求延期履行、制定清偿债务计划等承诺或行为的，应当认定为《民法典》第195条规定的当事人一方“同意履行义务”，同意履行是对诉讼时效利益的放弃，该放弃行为一旦完成不可反悔，债务承担情形下，构成原债务人对债务承认的，应当认定诉讼时效从债务承担意思表示到达债权人之日起中断，甲在时效期间届满后，承诺偿还债务，并且实际上承担了部分债务，构成甲对债务的承认，甲丧失时效利益，因此甲应当继续履行其义务，即偿还剩余的8万元，A选项正确，D选项错误，10万元的诉讼时效期间已经届满，不再发生中断，因为诉讼时效中断发生在期间届满之前，B选项错误，诉讼时效届满的法律后果是债务人取得时效抗辩权，但债权债务关系本身并没有消灭，乙的受领权仍然存在，因此乙不构成不当得利，C选项错误，此题存在技巧，B选项的杀伤力比较大，如果B选项正确，那么A选项一定正确，所以B选项是不可能正确的。

28. 【答案】D

【解析】限制民事行为能力人订立的合同，经法定代理人追认后，该合同有效，但纯获利益的合同或者与其年龄、智力、精神健康状况相适应而订立的合同是有效的，不必经法定代理人追认，《民法典总则编解释》第5条规定，限制民事行为能力人实施的民事法律行为是否与其年龄、智力、精神健康状况相适应，人民法院可以从行为与本人生活相关联的程度，本人的智力、精神健康状况能否理解其行为并预见相应的后果，以及标的、数量、价款或者报酬等方面认定，本题中，16周岁的甲为手机充值的行为在其能力范围之内，因此是有效的，C选项错误，借款合同、赠与合同以及购买消费卡的行为均效力未定，AB选项错误，D选项正确，

29. 【答案】D

【解析】所有权的取得分为原始取得和继受取得，所有权的原始取得是指没有经过前手权利人或者不依赖于前手权利人而取得财产的所有权，原始取得的方式主要包括劳动生产、先占、孳息、添附、善意取得、拾得遗失物、发现埋藏物等，所有权的继受取得，是指通过某种法律行为或基于法律行为以外的事实从原所有人处取得所有权，这种取得方式意味着原所有人的所有权基于一定的法律事实转归于新的所有人，亦即所有权的转移，所有权继受取得的方式主要包括买卖、赠与、继承、遗赠等，因此，ABC选项均属于所有权的原始取得，所以本题答案为D。

30. 【答案】C

【解析】本题考查的知识点为占有的分类，甲下班误将同事电脑当作自己的电脑带回家，属于无权占有、自主占有、直接占有和善意占有。故本题答案为C。

31. 【答案】C

【解析】根据《民法典》第317条第2款的规定，权利人悬赏寻找遗失物的，领取遗失物时应当按照承诺履行义务。本案中，乙虽不是拾得人，但只要归还遗失物，同样可以请求失主支付报酬。根据《民法典》第317条第3款的规定，拾得人侵占遗失物的，无权请求保管遗失物等支出的费用，也无权请求权利人按照承诺履行义务。甲拾得相机后具有侵占该遗失物的意图，因此甲无权请求失主支付报酬。

32. 【答案】A

【解析】本题存在三个问题：①毁损电脑的风险由谁承担；②违约责任由谁向谁主张；③侵权责任由谁向谁主张。买卖合同的风险是指买卖合同的标的物由于不可归责于买卖合同双方当事人的事由而毁损、灭失所造成的损失，风险负担是指该损失由谁来承担。出卖人货交第一承运人后，毁损、灭失的风险由买受人承担，但是不影响因出卖人履行债务不符合约定，买受人要求其承担违约责任的权利。因此，本题中，虽然电脑公司已将电脑交付快递公司，毁损、灭失的风险应由甲承担，但这并不影响因电脑公司履行债务

不符合约定，甲要求其承担违约责任的权利。基于合同的相对性原则，甲只能要求电脑公司而不是快递公司承担责任。甲与电脑公司之间存在合同关系，与快递公司之间不存在合同关系，电脑公司与快递公司之间存在货运合同，因此，电脑公司有权要求快递公司承担货物毁损的违约责任。因此，A 选项正确，B 选项错误。关于货物毁损的侵权责任，则应当由所有权人向侵权人主张。

《民法典》第 224 条规定：“动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但是法律另有规定的除外。”本题中，电脑公司委托快递公司将电脑运送至学校，可见双方约定了交付地点，在没将电脑交付给学校之前，不能发生物权变动，学校没有取得电脑所有权，所有权人依然为电脑公司，侵权人为快递公司。因此，CD 选项错误。

33. 【答案】B

【解析】《民法典》第 731 条规定，租赁物危及承租人的安全或者健康的，即使承租人订立合同时明知该租赁物质量不合格，承租人仍然可以随时解除合同。乙因甲交付的租赁房屋有害气体超标导致其无法入住，合同的目的不能实现，构成根本违约，因此乙有权解除合同。B 选项当选，A 选项不当选。甲乙之间签订的租赁合同并无无效事由，因此不能确认合同无效。C 选项不当选。题干中只说有害气体超标，并没有说因此给乙造成了身体损害，所以乙无权要求甲承担侵权责任。D 选项不当选。

34. 【答案】A

【解析】著作权的法定许可是指在一些特定的情形下，对未经他人许可而有偿使用他人享有著作权的作品的行为，依法不认定为侵权的法律制度。法定许可的情形主要有：①报刊转载摘编（作者申明除外）——注意，网站不再享有法定许可权，网站如果要转载，必须经许可同时付费（2015 年 4 月 17 日国家版权局发布了《关于规范网络转载版权秩序的通知》，其中第 1 条第 1 款和第 2 条第 2 款规定，网络媒体的转载不适用法定许可制度）；②翻唱（录制）——向词曲作者付费（注意，不是原表演者）；③广播、电视台一播放他人已发表的作品或者已出版的录音制品，但注意录像作品和电影不可以；④教科书——为九年义务教育和国家教育规划编写教科书。对于法定许可的情形，使用人不需要经过著作权人的许可，但需要向著作权人支付报酬。本题中属于第一种情形。甲在《雾都》发表小说后，未做版权声明，《传奇文摘》杂志社可以不经甲的许可转载该小说，但应当向甲支付报酬。因此，本题答案为 A。

35. 【答案】A

【解析】肖像权是指自然人依法制作、使用自己的肖像，借此享受一定利益并排除他人非法侵害的权利。肖像权属于支配权，其内容是肖像权人对自己肖像的支配，包括肖像制作权。华妃扮演者的剧照是其肖像制作权行使的结果，受法律保护。甲公司擅自使用电视剧《华妃传》中华妃扮演者的剧照为某化妆品做广告，侵犯了华妃扮演者的肖像权，A 选项当选。甲公司擅自使用华妃扮演者的肖像，并未损害对方的名誉，B 选项不当选。甲公司并未实施抄袭、篡改原作等行为，故不存在侵害著作权和邻接权，CD 选项不当选。

36. 【答案】D

【解析】《民法典》第 1198 条规定，宾馆、商场、银行、车站、机场、体育场馆、娱乐场所等经营场所、公共场所的经营者、管理者或者群众性活动的组织者，未尽到安全保障义务，造成他人损害的，应当承担侵权责任。因第三人的行为造成他人损害的，由第三人承担侵权责任；经营者、管理者或者组织者未尽到安全保障义务的，承担相应的补充责任。经营者、管理者或者组织者承担补充责任后，可以向第三人追偿。本题中，顾客乙被第三人甲打伤，该饭店未尽到安全保障义务。因此，对于乙的损害，甲应当承担侵权责任，饭店承担相应的补充责任。故本题答案为 D。

37. 【答案】C

【解析】根据《民法典》第 1168 条的规定，2 人以上共同实施侵权行为，造成他人损害的，应当承担连带责任。共同侵权是指 2 人以上共同故意或者共同过失侵害他人，依法承担连带责任的行为。本题中甲乙主观上都存在共同的过失，二者的行为结合在一起造成了丙损害的发生，是共同侵权行为。因此，本题

答案为C。《民法典》第1172条规定的构成共同因果关系的分别侵权：2人以上分别实施侵权行为造成同一损害，能够确定责任大小的，各自承担相应的责任；难以确定责任大小的，平均承担赔偿责任。

38. 【答案】A

【解析】物件损害责任是指为自己管领下的物件造成他人损害的，应当由物件的所有人、管理人或者使用人承担侵权责任的特殊侵权责任。《民法典》第1253条规定，建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。所有人、管理人或者使用人赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。房屋现处于承租人的使用中，承租人负有按照约定的方法使用租赁物，保证租赁物使用中的安全义务。甲顺手将剪刀放在阳台上造成了损害，应当是承租人甲对丙承担侵权责任。乙作为所有人，对该损害的发生没有过错，不承担责任。A选项当选，BD选项不当选。受害人丙是被侵权人，其损害应该由侵权人承担责任。丙不承担责任，C选项不当选。需要注意，如果是房屋的屋檐掉落致人损害，则由房屋所有权人承担责任，因为房屋所有权人有义务保证租赁物符合使用要求。

39. 【答案】C

【解析】《民法典》第397条规定，以建筑物抵押的，该建筑物占用范围内的建设用地使用权一并抵押。以建设用地使用权抵押的，该土地上的建筑物一并抵押。抵押人未依据前款规定一并抵押的，未抵押的财产视为一并抵押。本题中，基于房地一体主义原则，甲以其别墅设定抵押时，建设用地使用权视为一并抵押。另外，《民法典》第417条规定，建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产。该建设用地使用权实现抵押权时，应当将该土地上新增的建筑物与建设用地使用权一并处分。但是新增建筑物所得的价款，抵押权人无权优先受偿。本题中，因车库是设定抵押后新增的建筑物，不属于抵押财产范围。当然，实现抵押时，新增车库应当一并拍卖，只是抵押权人就车库价值不能优先受偿。因此，C选项当选。

40. 【答案】D

【解析】根据《民法典》第1020条的规定，合理实施下列行为的，可以不经肖像权人同意：为个人学习、艺术欣赏、课堂教学或者科学研究，在必要范围内使用肖像权人已经公开的肖像；为实施新闻报道，不可避免地制作、使用、公开肖像权人的肖像；为依法履行职责，国家机关在必要范围内制作、使用、公开肖像权人的肖像；为展示特定公共环境，不可避免地制作、使用、公开肖像权人的肖像；为维护公共利益或者肖像权人合法权益，制作、使用、公开肖像权人的肖像的其他行为。本题中，记者在报道中使用甲、乙、丙的肖像不构成肖像权侵权，所以B选项不当选。隐私权是指自然人享有的对自己的个人隐私进行支配并排除他人非法干涉的人格权。甲容留乙、丙吸毒的行为以及甲与艺人乙、丙一起赌博的行为是违法行为，不属于隐私权的保护范围。所以AC选项不当选。

二、多项选择题

41. 【答案】BC

【解析】关于重婚罪，《刑法》第258条规定，有配偶而重婚的，或者明知他人有配偶而与之结婚的，处2年以下有期徒刑或者拘役。可见，重婚罪是公诉犯罪，因此A选项不当选。关于侮辱罪、诽谤罪，《刑法》第246条第1、2款规定，以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处3年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。可见侮辱罪属于告诉才处理的犯罪，因此B选项当选。关于暴力干涉婚姻自由罪，《刑法》第257条规定，以暴力干涉他人婚姻自由的，处2年以下有期徒刑或者拘役。犯前款罪，致使被害人死亡的，处2年以上7年以下有期徒刑。第1款罪，告诉的才处理。因此C选项当选。关于遗弃罪，《刑法》第261条规定，对于年老、年幼、患病或者其他没有独立生活能力的人，负有扶养义务而拒绝扶养，情节恶劣的，处5年以下有期徒刑、拘役或者管制。可见，遗弃罪是公诉犯罪，因此D选项不当选。

42. 【答案】ACD

【解析】刑法上的认识错误，是指行为人对自己行为的法律性质、后果和有关的事实情况发生了误解，刑法上的认识错误可分为两种：①法律上的认识错误，包括假想非罪和假想犯罪，假想非罪，行为被法律规定为犯罪，而行为人误认为不是犯罪。假想犯罪，行为并没有被规定为犯罪，而行为人误以为是犯罪。行为人对自己犯罪行为的罪名和罪行轻重发生误解，②事实上的认识错误，事实上的认识错误分为：客体错误、对象错误、手段错误、行为偏差（打击错误）、因果关系错误，AC选项属于假想非罪，当选，D选项丁误将抢劫罪认为是盗窃罪，属于行为人对自己犯罪行为的罪名和罪行轻重发生误解，当选，B选项，不是法律认识错误，而是犯罪动机问题，犯罪动机不影响故意杀人罪的成立，不当选。

43. 【答案】AC

【解析】限制死刑适用对象：犯罪的时候不满18周岁的人和审判的时候怀孕的妇女，不适用死刑，另外，审判的时候已满75周岁的人，除非以特别残忍手段致人死亡的，一般不适用死刑，故本题答案为AC，犯罪时又聋又哑的人可以适用死刑，只是按照《刑法》第19条的规定，可以从轻、减轻或者免除处罚。

44. 【答案】ABD

【解析】在生产、销售的饲料中添加盐酸克仑特罗等禁止在饲料和动物饮用水中使用的药品，或者销售明知是添加有该类药品的饲料，情节严重的，以非法经营罪追究刑事责任，故A选项当选，违反国家规定，采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法，擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动，扰乱电信市场管理秩序，情节严重的，以非法经营罪定罪处罚，故B选项当选，违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应以非法经营罪定罪处罚，故D选项当选，C选项的行为成立组织出卖人体器官罪，故不当选。

45. 【答案】AC

【解析】禁止被判处管制、宣告缓刑的犯罪分子在管制执行期间、缓刑考验期限内接触的人员有：未经对方同意，禁止接触控告人、批评人、举报人及其法定代理人、近亲属，故A选项正确，禁止被判处管制、宣告缓刑的犯罪分子在管制执行期间、缓刑考验期限内从事的活动包括：利用从事特定生产经营活动实施犯罪的，禁止从事相关生产经营活动，故C选项正确，禁止令的执行期限，从管制、缓刑执行之日起计算，故D选项错误，甲的行为与学校无关，所以禁止甲进入学校，于法无据，故B选项错误。

46. 【答案】ABCD

【解析】根据《民法典》第40条的规定，自然人下落不明满2年的，利害关系人可以向人民法院申请宣告其为失踪人，《民法典总则编解释》第14条规定，人民法院审理宣告失踪案件时，下列人员应当认定为《民法典》第40条规定的利害关系人：①被申请人的近亲属。②依据《民法典》第1128条、第1129条规定对被申请人有继承权的亲属。③债权人、债务人、合伙人等与被申请人有民事权利义务关系的民事主体，但是不申请宣告失踪不影响其权利行使、义务履行的除外，因此，本题答案为ABCD。

47. 【答案】BC

【解析】本题中丁误将乙的瓷砖当作甲的瓷砖予以使用，甲的财产消极增加，且没有法律上的依据；乙遭受现有财产的损失，二者之间存在因果关系。因甲乙之间成立不当得利之债，甲应当予以返还，因此B选项当选。丙公司的工人丁构成了侵权，但因其为职务行为，因此应当由其用人单位丙公司承担替代的责任，丁不承担责任，因此C选项当选，D选项不当选。

48. 【答案】AB

【解析】相邻关系是指相互毗邻的不动产的所有人或使用人因对不动产行使所有权而发生的权利义务关系。根据《民法典》第293条的规定，建造建筑物，不得违反国家有关工程建设标准，不得妨碍相邻建筑物的通风、采光和日照。甲租赁乙的别墅，且在租赁期间擅自加高房屋，使邻居丙的房屋采光受到严重影响，侵害了丙的相邻权，丙可依据上述规定要求乙作为别墅的所有人、甲作为别墅的使用人排除妨碍。

AB 选项当选，C 选项不当选。考生需要注意，排除妨害的权利，既可以对行为妨害人，也可以对状态妨害人行使。乙所有的别墅与丙所有的房屋是互不接触的相邻单独建筑，不存在建筑物区分所有权。D 选项不当选。

49. 【答案】ABCD

【解析】医疗损害责任，是指医疗机构及医务人员在医疗过程中因存在过错，致使患者在诊疗活动中受到损害，由医疗机构承担赔偿责任。医疗损害的赔偿内容主要有：医疗费、误工费、住院伙食补助费、护理费、残疾辅助器具费、营养费、丧葬费、被扶养人生活费、交通费、住宿费、死亡赔偿金、精神损害抚慰金。甲医院将患者的左肾切除，构成医疗事故，应当承担医疗损害赔偿责任。因此，本题答案为 ABCD。

50. 【答案】AC

【解析】根据我国《民法典》第 1127 条和第 1129 条的规定，遗产按照下列顺序继承：第一顺序：配偶、子女、父母，对公婆、岳父母尽了主要赡养义务的丧偶儿媳、丧偶女婿，也作为第一顺序继承人；第二顺序：兄弟姐妹，祖父母，外祖父母。继承开始后，由第一顺序继承人继承，第二顺序继承人不继承，没有第一顺序继承人的，才由第二顺序继承人继承。因此作为丙的配偶的甲和丙的女儿作为丙的第一顺序继承人，有权继承其遗产，AC 选项当选。继子女继承遗产需以“有扶养关系”为前提，甲的儿子并未与丙生活在一起，无抚养关系，因此无继承权，B 选项不当选。丙的姐姐丁属于第二顺序继承人，因为已经有了第一顺序继承人了，因此丁不享有继承权，D 选项不当选。

三、简答题

51. 【答案】

缓刑的适用条件包括：（1）犯罪分子被判处拘役或者 3 年以下有期徒刑的刑罚；

（2）犯罪分子的犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，且宣告缓刑不会对所居住社区产生重大的不良影响；

（3）犯罪分子不是累犯或者犯罪集团的首要分子。

【点评及思路】本题考查的知识点是缓刑的适用条件，属于常规考点，缓刑是重要的量刑制度之一，考生应全面掌握，根据我国《刑法》的规定，适用缓刑必须具备下列条件：

（1）犯罪分子被判处拘役或者 3 年以下有期徒刑的刑罚，缓刑的附条件不执行原判刑罚的特点，决定了缓刑的适用对象只能是罪行较轻的犯罪分子。

（2）犯罪分子的犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，且宣告缓刑不会对所居住社区产生重大的不良影响，这是适用缓刑的实质条件，它们必须同时具备。

（3）犯罪分子不是累犯或者犯罪集团的首要分子，累犯屡教不改、主观恶性较深，有再犯之虞，适用缓刑难以防止其再犯新罪，犯罪集团的首要分子社会危害性较大，即使累犯和犯罪集团的首要分子被判处拘役或 3 年以下有期徒刑，也不能适用缓刑，犯罪人具有上述条件，可以宣告缓刑，犯罪主体具有上述条件，而且是不满 18 周岁的人、怀孕的妇女或者已满 75 周岁的人，就应当宣告缓刑。

52. 【答案】

组织、领导、参加恐怖组织罪是指组织、领导、积极参加和参加恐怖组织活动的行为，本罪是危害公共安全罪之一。

（1）客体要件，本罪侵犯的客体为公共安全，即不特定多数人的生命、健康和财产安全。

（2）客观要件，本罪在客观方面表现为组织、领导、积极参加和参加恐怖组织活动，本罪是选择性罪名，行为人只要实施了组织、领导、积极参加或者参加恐怖组织行为之一，便成立本罪，行为人实施两个或两个以上的行为，比如既组织又领导恐怖组织的，也只成立本罪一罪，不实行数罪并罚。

（3）主体要件，本罪的主体为一般主体，即凡达到刑事责任年龄、具备刑事责任能力的人均可构成本罪。

（4）主观要件，本罪在主观方面表现为直接故意，并且具有进行恐怖活动的目的，即行为人以长期实

行某种或某几种恐怖犯罪活动为目的，明知组织、领导恐怖组织是危害公共安全的犯罪行为，却仍然故意组织、领导。或者明知是恐怖组织而积极参加或参加。

【点评及思路】本题考查的知识点是组织、领导、参加恐怖组织罪的构成要件，这一罪名属于刑法分则中比较冷门的罪名，这提醒考生应全面背诵刑法分则的内容，同时，组织、领导、参加恐怖组织罪也是2015年《刑法修正案（九）》所修改的罪名。

53. 【答案】

职务发明创造是指执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。

（1）执行本单位任务所完成的职务发明创造具体包括：①在本职工作中作出的发明创造。②履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造。③退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。

（2）主要是利用本单位的物质技术条件完成的职务发明创造，所谓“本单位的物质技术条件”，是指单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公布的技术资料等。

【点评及思路】本题考查的知识点是职务发明创造的具体类型，属于比较冷门的知识点，回答好不容易，考生应注意《专利法实施细则》在2010年的修订，使用最新的表述回答该问题。

54. 【答案】

滥用代理权的主要情形及其效力如下：

（1）自己代理，这是指代理人以被代理人的名义与自己进行民事活动的行为，该行为通常为无效行为，但是被代理人同意或者追认的除外。

（2）双方代理，这是指代理人以被代理人的名义与自己代理的其他人进行民事活动的行为，该行为原则上无效，但是被代理的双方同意或者追认的除外。

（3）代理人与相对人恶意串通，此种行为属于无效的民事行为，给被代理人造成损害的，由代理人和相对人负连带责任。

【点评及思路】本题考查的知识点是滥用代理权的主要情形及其效力，属于传统的重点知识，考生主要应注意滥用代理权和无权代理的区别，不能混淆这两个概念。

四、辨析题

55. 【答案】

（1）这种说法不完全正确。

（2）根据刑法理论，危害结果是犯罪的选择要件，即危害结果并不是所有犯罪的构成要件，对于行为犯而言，行为人只要实施了特定行为，其行为就构成犯罪，应负刑事责任。

（3）因果关系是结果犯承担刑事责任的客观基础，如果行为和结果没有因果关系，就不能认为危害行为产生了危害结果，行为人就对相应的危害结果承担刑事责任（对于过失犯罪和间接故意犯罪而言），或者不承担犯罪既遂的刑事责任（对于直接故意犯罪而言）。

【点评及思路】本题考查的知识点是因果关系对承担刑事责任的意义，考生应辩证看待这一观点，分别回答其正确的一面和错误的一面，按照刑法理论，承担刑事责任的基础是犯罪构成要件，犯罪客观要件的必备要件是危害行为，危害结果是选择要件，刑法因果关系是危害行为与危害结果之间的一种客观的引起与被引起的联系，因而，对于行为犯而言，行为人只要实施了特定行为，其行为就构成犯罪，应负刑事责任，此时，一般不存在解决刑法因果关系的问题，对于结果犯而言，因果关系是结果犯承担刑事责任的客观基础，如果行为和结果之间没有因果关系，就不能认为危害行为产生了危害结果，行为人就对相应的危害结果承担刑事责任（对于过失犯罪和间接故意犯罪而言），或者不承担犯罪既遂的刑事责任（对于直接故意犯罪而言）。

56. 【答案】

（1）这种说法不完全正确。

(2) 基于法律行为设立不动产物权的，登记生效主义是原则，登记对抗主义是例外，根据《民法典》的有关规定，不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生法律效力。未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外，登记为物权变动生效要件的情形主要有：因买卖、赠与、互易等行为发生不动产所有权变动的，建设用地使用权的出让与转让的，居住权的设立，不动产抵押权的设立等，登记为对抗要件的情形主要有：土地承包经营权互换、转让的，未经登记，不得对抗善意第三人。地役权设立时，未经登记，不得对抗善意第三人，此外，国家所有权亦无需登记。

(3) 非基于法律行为的物权变动则不需要公示，就其中的不动产变动而言，登记既非生效要件也不是对抗要件，而是处分要件，如根据《民法典》第 229 条至第 232 条的规定，因人民法院、仲裁机构的法律文书或者人民政府的征收决定等，导致物权设立、变更、转让或者消灭的，自法律文书或者征收决定等生效时发生法律效力，因继承取得物权的，自继承开始时发生法律效力，因合法建造、拆除房屋等事实行为设立或者消灭物权的，自事实行为成就时发生法律效力，依照以上规定享有不动产物权的，处分该物权时，依照法律规定需要办理登记的，未经登记，不发生物权效力。

【点评及思路】本题考查的知识点是不动产的物权变动，考生首先需要掌握引起不动产物权变动的两类原因，一是基于法律行为的物权变动，二是非基于法律行为的物权变动，这两个原因是回答此题的两条线索，然后考生需要搞清登记的两种效力，一为登记生效主义，二为登记对抗主义，考生熟练掌握上述知识，则能较好回答本题。

另外，考生应注意此处“法律文书”的范围，根据《民法典物权编解释（一）》第 7 条的规定，人民法院、仲裁机构在分割共有不动产或者动产等案件中作出并依法生效的改变原有物权关系的判决书、裁决书、调解书，以及人民法院在执行程序中作出的拍卖成交裁定书、变卖成交裁定书、以物抵债裁定书，应当认定为《民法典》第 229 条所称导致物权设立、变更、转让或者消灭的人民法院、仲裁机构的法律文书。

五、法条分析题

57. 【答案】

(1) “滥用职权”是指国家机关工作人员超越职权，违法决定、处理其无权决定、处理的事项，或者违反规定处理公务的行为。

(2) “玩忽职守”是指国家机关工作人员严重不负责任，不履行或者不认真履行职责的行为。

(3) “本法另有规定的，依照规定”是解决法条竞合的处理原则，在此具体是指国家机关工作人员的滥用职权、玩忽职守行为，在刑法其他条文有另外规定时按照另外规定处理。

【点评及思路】本题考查的知识点是对滥用职权罪和玩忽职守罪的理解，这两罪都是渎职类犯罪中的重点罪名。

关于第(1)问，考生可进一步回答滥用职权的行为的主要表现，主要包括以下四种情况：①超越职权，擅自决定或处理没有具体决定、处理权限的事项。②玩弄职权，随心所欲地对事项作出决定或者处理。③故意不履行应当履行的职责，或者任意放弃职责。④以权谋私、假公济私，不正确地履行职责。

关于第(2)问，玩忽职守，是指国家机关工作人员严重不负责任，不履行或不正确履行职责，其行为方式一般为不作为，但有时也可以表现为作为，其中，作为形式的玩忽职守是指行为人积极地实施与其职务或者职责相背离的行为，致使国家、人民利益和公私财产遭受重大损失。不作为形式的玩忽职守是指行为人消极地不履行职务或者职责，致使国家、人民利益和公私财产遭受重大损失的行为。

关于第(3)问，《刑法》第 397 条关于滥用职权罪和玩忽职守罪的规定是普通法条，其他滥用职权犯罪行为的規定是特别法条，当行为人的行为同时符合第 397 条和其他法条的规定时，应按照其他法条即特别法条的规定定罪论处，如徇私枉法罪也是滥用职权行为，但是有了特别法条的规定，应按照特别法优于一般法的原则处理。

58. 【答案】

(1) “胁迫”是指行为人以给另一方当事人或者其近亲属的生命、身体、健康、名誉、财产等方面造成损害为要挟，迫使另一方当事人违背真实意愿结婚的情况。

(2) 因受胁迫而请求撤销婚姻的, 只能是受胁迫一方的婚姻关系当事人本人。

(3) 除斥期间。

【点评及思路】本题考查的知识点是可撤销婚姻和除斥期间, 回答本题, 需要掌握两方面的基础知识:

①我国《民法典》婚姻家庭编关于可撤销婚姻的制度, 包括可撤销婚姻的法定事由、行使撤销权的主体、行使撤销权的期间以及婚姻被撤销的后果。②除斥期间与诉讼时效的区别, 其属于《民法典》总则编的知识, 因此, 本题具有一定的综合性, 但整体来说难度不大。

六、案例分析题

59. 【答案】

(1) 甲的行为构成拐卖儿童罪, 甲年满 16 周岁, 具有刑事责任能力, 以出卖为目的将儿童置于自己的控制之下, 其行为符合拐卖儿童罪的犯罪构成, 甲在拐卖过程中, 过失造成被拐卖人死亡, 属于拐卖儿童罪加重处罚的情形。

(2) 乙的行为构成故意杀人罪, 乙未满 16 周岁, 对拐卖儿童的行为不承担刑事责任, 乙明知不看管 3 岁儿童可能导致死亡结果, 却放任死亡结果发生, 其行为构成故意杀人罪。

(3) 甲和乙的行为不构成共同犯罪, 乙对拐卖儿童行为不承担刑事责任, 因此二人不构成拐卖儿童罪的共同犯罪。对于被害人的死亡, 甲为过失, 乙为故意, 二人不构成故意杀人罪的共同犯罪。

【点评及思路】本题考查的知识点是对刑事责任能力年龄、拐卖儿童罪、故意杀人罪、共同犯罪理论的理解, 具有一定的综合性, 考生另外应注意《刑法修正案(十一)》对刑事责任能力年龄的修正, 拐卖儿童罪是指以出卖为目的, 拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转儿童的行为, 拐卖行为造成被拐卖的儿童死亡的, 是法定加重处罚情节, 由于拐卖儿童罪本身包含非法拘禁的内容, 所以即使存在非法拘禁情形的, 也不再认定为非法拘禁罪, 故意杀人罪是指故意非法剥夺他人生命的行为, 用不作为的方式实施故意杀人犯罪属于不真正不作为犯, 《刑法》第 17 条第 2 款规定, 已满 14 周岁不满 16 周岁的人, 犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的, 应当负刑事责任, 本案中, 甲、乙以出卖为目的将儿童置于自己的控制之下, 共同实施了拐卖儿童的行为, 其中甲已满 16 周岁, 具有刑事责任能力, 其行为构成拐卖儿童罪。乙已满 14 周岁不满 16 周岁, 对拐卖儿童行为不承担刑事责任。

此外, 乙在独自看管孩子期间, 弃之不顾, 面对甲的返回要求不予理会, 最终导致孩子饿死, 其明知不看管 3 岁儿童可能导致死亡结果, 却放任死亡结果发生, 属于以不作为的方式故意杀人, 构成故意杀人罪, 甲对于死亡结果没有故意, 但是该结果是由其拐卖行为导致, 且其对这一结果具有预见可能性, 故甲应承担拐卖儿童致人死亡的加重处罚责任, 综上可得, 甲单独成立拐卖儿童罪, 乙单独成立故意杀人罪, 二人不构成共同犯罪。

60. 【答案】

(1) 借款合同在甲提供借款时(即 2012 年 4 月 28 日)生效(应为成立), 因为自然人之间的借款合同, 自贷款人提供借款时生效(应为成立)。

(2) 丙的担保是一般保证。借款合同约定, 丙在乙到期无力还款时承担保证责任, 此种约定应依法认定为一般保证。对甲多借给乙的 20 万元, 丙不承担保证责任, 因这 20 万元系未经保证人书面同意加重保证责任, 保证人依法对加重的部分不承担保证责任。

(3) 不因此而无效。债权人转让债权的, 应当通知债务人, 但无须征得债务人同意。

【点评及思路】本题考查的知识点是借款合同、保证和债权转让, 属于常规考点, 在往后的备考中考生也应注意对相关知识的掌握, 这些知识点即使不在案例分析题中考查, 选择题也会有所涉及。

本题第(1)问考查的知识点是自然人之间借款合同的成立时间, 《民法典》第 679 条规定, 自然人之间的借款合同, 自贷款人提供借款时成立, 考生应注意原《合同法》相关法条的“生效”到现《民法典》本条“成立”的表述变化。

本题第(2)问考查的知识点是保证, 《民法典》第 687 条第 1 款规定, 当事人在保证合同中约定, 债

务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为一般保证，《民法典》第 695 条第 1 款规定，债权人和债务人未经保证人书面同意，协商变更主债权债务合同内容，减轻债务的，保证人仍对变更后的债务承担保证责任。加重债务的，保证人对加重的部分不承担保证责任。

本题第（3）问考查的知识点是债权转让的生效条件，考生需要分别掌握债权转让在让与人与受让人之间的生效条件和债权转让对债务人的生效条件，《民法典》第 546 条第 1 款规定，债权人转让债权，未通知债务人的，该转让对债务人不发生效力，债权转让合同不以通知债务人或者债务人同意为生效要件，通知仅是债权转让合同对债务人生效的要件，至于债务人是否同意则无需考虑。

在《民法典》出台前，考生需要掌握大量相关法律法规和司法解释，但现在本题答案均可在《民法典》中找到答案，因此《民法典》实际上减轻了考生的学习压力。

